

1002215-45.2022.8.26.0297

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

Magistrado: FERNANDO ANTONIO DE LIMA

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 [tráfico de drogas]".

Ao analisar o HC, o ministro Lewandowski destacou que vícios formais impediriam a análise do pedido. Entretanto, diante do cenário de flagrante violação aos direitos humanos, e fundamentado na Constituição brasileira e em normas internacionais de direitos humanos, decidiu conceder de ofício o pedido de habeas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua 15, nº 2210, Jales - SP - cep 15700-038

SENTENÇA

Processo nº:

1002215-45.2022.8.26.0297

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO-Liquidação / Cumprimento / Execução-Obrigação de Fazer / Não Fazer

Requerente:

Anselmo Nogueira da Silva

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO ANTONIO DE LIMA

VISTOS.

Trata-se de demanda, em que a parte autora, Policial Militar, busca: a) residir na sede da 2ª CIA PM - 2ª Companhia da Polícia Militar (Jales-SP) ou em qualquer das unidades policiais ou cidades (GPPMs - Grupo Policial Militar) que fazem parte da 2ª CIA PM, pedido esse, formulado, inclusive, em sede de tutela antecipada.

O pedido é procedente.

Observa-se, dos autos, que o requerente é Policial Militar, residente na 1ª Companhia da Polícia Militar de São Paulo-SP, onde onde trabalha (1ª CIA/PM; 2º Batalhão de Polícia de Trânsito).

Percebe-se que o autor está exercendo suas funções na cidade de São Paulo-SP, há aproximadamente 580 quilômetros de distância dos laços familiares aqui na cidade de Jales-SP.

Consta que realizou pedido administrativo de remoção, para prestar auxílio integral de acompanhamento e tratamento de saúde ao seu genitor OVIDIO SILVA, pessoa com Osteoartrite Poliarticular da Coluna Lombar, enfermidade irreversível, bem como padece de problemas psiquiátricos, com ideações suicidas. Referido pedido foi indeferido com base no parágrafo único do artigo 11 da I-2-PM.

Com efeito, é possível a remoção para acompanhar no tratamento de saúde de parente próximo:

RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR. GENITOR COM DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE

ACOMPANHAMENTO PERMANENTE. LOCAL DE DOMICÍLIO E LOTAÇÃO MUITO DISTANTE. A Instrução I-2-PM prevê a hipótese de transferência do policial militar em casos de comprovada excepcionalidade e necessidade, no interesse particular do servidor. Havendo parecer favorável do superior hierárquico do local de lotação do interessado e demonstrado a excepcional necessidade de transferência, deve o policial ser contemplado para que possa auxiliar no tratamento de doença grave de seu genitor, documentalmente demonstrada pela apresentação de atestados e exames médicos. Conciliação do direito do interesse do servidor e sua dignidade com o interesse público. Especial proteção do Estado à família. Artigo 230 da Constituição Federal. Precedentes desta C. Corte, do E. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal. Sentença reformada. Recurso provido. Apelação nº 1006953-13.2014.8.26.0053, Relator(a): Marcelo Berthe; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Data de registro: 03/09/2014).

O instituto da interpretação conforme ganha campo aplicativo nas normas plurissignificativas ou polissêmicas. Isto é, quando uma norma abaixo da CF admite mais de um sentido, o instituto, típico do controle de constitucionalidade e da hermenêutica constitucional, entra em cena.

Havendo duas possibilidades interpretativas, o intérprete deve buscar aquela possibilidade que se compatibilize com a Constituição Federal.

Nesse cenário, a hipótese mais compatível à Constituição é a que prestigia a família. Isso porque a família é a base da sociedade e tem a proteção especial do Estado, nos termos do que dispõe o art. 226, caput, da Constituição Federal. Assim como a lua ilumina os pântanos terrestres, o art. 130 da Constituição Estadual prestigia o art. 226, caput, da Constituição Federal, quando o primeiro apresenta o conceito ampliativo.

Não se haverá de construirmos uma sociedade livre, justa e solidária (CF, art. 3º, inciso I), se não criarmos os meios necessários para que a família, essa tão desprezada instituição nos dias atuais, retome o seu valor, a sua importância, o seu prestígio.

Sinais de decadência social apontam no sentido do atassalhar, do destruir os laços familiares.

No neoconstitucionalismo, nesta era da pós-modernidade, os princípios constitucionais ostentam plena validade normativa, ao ponto de prevalecer, em muitos casos, sobre as regras, ou, até mesmo, dar às regras o sentido que os princípios possam-lhe conferir.

As normas e princípios constitucionais, que prestigiam a família, ostentam uma natureza inclusiva. Nesse sentido, diante do princípio de preservação da família, é possível uma hermenêutica criativa, inclusiva, que parta do texto constitucional e ilumine a interpretação das normas abaixo da Constituição Federal, com vistas a amparar a família.

Sobre a hermenêutica construtiva no âmbito dos direitos fundamentais e dos princípios constitucionais de proteção da família, sobre a normatividade dos princípios constitucionais, sobre a adaptação das normas que estão abaixo da Constituição aos princípios da Constituição Federal, é importante conferir o que vem decidindo o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

E M E N T A: UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO - ALTA RELEVÂNCIA SOCIAL E JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA QUESTÃO PERTINENTE ÀS UNIÕES HOMOAFETIVAS - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO RECONHECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA COMO ENTIDADE FAMILIAR: POSIÇÃO CONSAGRADA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF 132/RJ E ADI 4.277/DF) - O AFETO COMO VALOR JURÍDICO IMPREGNADO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL: A VALORIZAÇÃO DESSE NOVO PARADIGMA COMO NÚCLEO CONFORMADOR DO CONCEITO DE FAMÍLIA (grifei) - O DIREITO À BUSCA DA FELICIDADE, VERDADEIRO POSTULADO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO E EXPRESSÃO DE UMA IDÉIA-FORÇA QUE DERIVA DO PRINCÍPIO DA ESSENCIAL DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (grifei) - ALGUNS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA SUPREMA CORTE AMERICANA SOBRE O DIREITO FUNDAMENTAL À BUSCA DA FELICIDADE - PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA (2006): DIREITO DE QUALQUER PESSOA DE CONSTITUIR FAMÍLIA, INDEPENDENTEMENTE DE SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL OU IDENTIDADE DE

GÊNERO - DIREITO DO COMPANHEIRO, NA UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA, À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE DE SEU PARCEIRO, DESDE QUE OBSERVADOS OS REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL - O ART. 226, § 3º, DA LEI FUNDAMENTAL CONSTITUI TÍPICA NORMA DE INCLUSÃO (grifei) - A FUNÇÃO CONTRAMAJORITÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - A PROTEÇÃO DAS MINORIAS ANALISADA NA PERSPECTIVA DE UMA CONCEPÇÃO MATERIAL DE DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL - O DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE IMPEDIR (E, ATÉ MESMO, DE PUNIR) "QUALQUER DISCRIMINAÇÃO ATENTATÓRIA DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS" (CF, ART. 5º, XLI) - A FORÇA NORMATIVA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E O FORTALECIMENTO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL: ELEMENTOS QUE COMPÕEM O MARCO DOUTRINÁRIO QUE CONFERE SUPORTE TEÓRICO AO NEOCONSTITUCIONALISMO (grifei) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. NINGUÉM PODE SER PRIVADO DE SEUS DIREITOS EM RAZÃO DE SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL. - Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser privado de direitos nem sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo de sua orientação sexual. Os homossexuais, por tal razão, têm direito de receber a igual proteção tanto das leis quanto do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República, mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que puna, que exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão de sua orientação sexual. RECONHECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO ENTIDADE FAMILIAR. - O Supremo Tribunal Federal - apoiando-se em valiosa hermenêutica construtiva e invocando princípios essenciais (como os da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, da intimidade, da não discriminação e da busca da felicidade) - reconhece assistir, a qualquer pessoa, o direito fundamental à orientação sexual, havendo proclamado, por isso mesmo, a plena legitimidade ético-jurídica da união homoafetiva como entidade familiar, atribuindo-lhe, em consequência, verdadeiro estatuto de cidadania, em ordem a permitir que se extraiam, em favor de parceiros homossexuais, relevantes consequências no plano do Direito, notadamente no campo previdenciário, e, também, na esfera das relações sociais e familiares. - A extensão, às uniões homoafetivas, do mesmo regime jurídico aplicável à união estável entre pessoas de gênero distinto justifica-se e legitima-se pela direta incidência, dentre outros, dos princípios constitucionais da igualdade, da liberdade, da dignidade, da segurança jurídica e do postulado constitucional implícito que consagra o direito à busca da felicidade, os quais configuram, numa estrita dimensão que privilegia o sentido de inclusão decorrente da própria Constituição da República (art. 1º, III, e art. 3º, IV), fundamentos autônomos e suficientes aptos a conferir suporte legitimador à qualificação das conjugalidades entre pessoas do mesmo sexo como espécie do gênero entidade familiar. - Toda pessoa tem o direito fundamental de constituir família, independentemente de sua orientação sexual ou de identidade de gênero. A família resultante da união homoafetiva não pode sofrer discriminação, cabendo-lhe os mesmos direitos, prerrogativas, benefícios e obrigações que se mostrem acessíveis a parceiros de sexo distinto que integrem uniões heteroafetivas. A DIMENSÃO CONSTITUCIONAL DO AFETO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA FAMÍLIA MODERNA. - O reconhecimento do afeto como valor jurídico impregnado de natureza constitucional: um novo paradigma que informa e inspira a formulação do próprio conceito de família. Doutrina. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E BUSCA DA FELICIDADE. - O postulado da dignidade da pessoa humana, que representa - considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) - significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País, traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. Doutrina. - O princípio constitucional da busca da felicidade, que decorre, por implicitude, do núcleo de que se irradia o postulado da dignidade da pessoa humana, assume papel de extremo relevo no processo de afirmação, gozo e expansão dos direitos fundamentais, qualificando-se, em função de sua própria teleologia, como fator de neutralização de práticas ou de omissões lesivas cuja ocorrência possa comprometer, afetar ou, até mesmo, esterilizar direitos e franquias individuais. - Assiste, por isso mesmo, a todos, sem qualquer exclusão, o direito à busca da felicidade, verdadeiro

postulado constitucional implícito, que se qualifica como expressão de uma idéia-força que deriva do princípio da essencial dignidade da pessoa humana. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e da Suprema Corte americana. Positivização desse princípio no plano do direito comparado. A FUNÇÃO CONTRAMAJORITÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A PROTEÇÃO DAS MINORIAS. - A proteção das minorias e dos grupos vulneráveis qualifica-se como fundamento imprescindível à plena legitimação material do Estado Democrático de Direito. - Incumbe, por isso mesmo, ao Supremo Tribunal Federal, em sua condição institucional de guarda da Constituição (o que lhe confere “o monopólio da última palavra” em matéria de interpretação constitucional), desempenhar função contramajoritária, em ordem a dispensar efetiva proteção às minorias contra eventuais excessos (ou omissões) da maioria, eis que ninguém se sobrepõe, nem mesmo os grupos majoritários, à autoridade hierárquico-normativa e aos princípios superiores consagrados na Lei Fundamental do Estado. Precedentes. Doutrina (grifei).

(RE 477554 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/08/2011, DJe-164 DIVULG 25-08-2011 PUBLIC 26-08-2011 EMENT VOL-02574-02 PP-00287 RTJ VOL-00220- PP-00572)

Como se vê, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL construiu uma interpretação que aumentou o alcance semântico do art. 226, §3º, da Constituição Federal. Não há previsão expressão da união homoativa, mas apenas da união entre pessoas de sexo diferente. Mesmo assim, mediante uma hermenêutica construtiva, o STF ampliou o conceito de união estável, para abranger as pessoas do mesmo sexo.

Da mesma maneira agimos nesta lide. Se queremos mesmo erigir uma hermenêutica construtiva, baseada no princípio constitucional da preservação da família - e se consideramos, de verdade, como já faz o STF, que, na ordem moderna do neoconstitucionalismo, os princípios constitucionais ostentam força normativa - a única interpretação possível é a de admitir a remoção do autor, para acompanhar o tratamento de saúde de seu genitor.

A vaga pode ser preferencialmente para Jales-SP. Não havendo vaga em Jales-SP, o deslocamento pode ser para qualquer das unidades ou cidades que componham a 2ª Companhia de Jales-SP. O termo residência, portanto, haverá de receber essa interpretação ampliativa, baseada na força normativa da principiologia constitucional - tudo isso com base na técnica da interpretação conforme, abundantemente utilizada pelo STF no âmbito do controle de constitucionalidade. Não bastasse a proteção constitucional, também no campo dos tratados internacionais sobre direitos humanos há a expressa previsão de tutela da família.

Nos termos do artigo 17 da Convenção Americana dos Direitos Humanos, “a família é o elemento natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado”. Referida Convenção data do dia 22 de novembro de 1969, assinada em San José, em Costa Rica.

Constitui norma de observância obrigatória no Brasil, de modo que ao Estado e à sociedade incumbe a adoção de mecanismos tutelares da família.

Com efeito, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Ricardo Lewandowski concedeu habeas corpus de ofício, para que uma gestante deixasse o cárcere e cumprisse a prisão preventiva na residência. Baseou-se, o digníssimo Ministro, em regras internacionais de direitos humanos. Além disso, conclamou aos juízes a aplicação das normas e princípios internacionais de direitos humanos e a jurisprudência das Cortes Internacionais de Direitos Humanos:

Quinta-feira, 08 de janeiro de 2015

Regras internacionais de direitos humanos garantem prisão domiciliar a gestante
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus (HC 126107) a uma mulher grávida que se encontrava presa na Penitenciária Feminina da cidade de São Paulo. Com a decisão, a gestante permanecerá presa preventivamente, mas em casa.

No pedido, a Defensoria Pública paulista informa que a presa é “portadora de cardiopatia grave” e está “em estágio avançado de gestação”. Ademais, “encontra-se presa preventivamente, desde 20/5/2014, em razão da suposta prática do crime

previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 [tráfico de drogas]”.

Ao analisar o HC, o ministro Lewandowski destacou que vícios formais impediriam a análise do pedido. Entretanto, diante do cenário de flagrante violação aos direitos humanos, e fundamentado na Constituição brasileira e em normas internacionais de direitos humanos, decidiu conceder de ofício o pedido de habeas corpus.

Constituição Federal

No plano da Constituição Federal brasileira, o presidente do STF ressaltou que a individualização da pena é uma garantia fundamental do Estado Democrático de Direito, de modo que o nascituro não pode “pagar” criminalmente pelos supostos atos, ainda em apuração, praticados por sua genitora.

“Se é certo que esse fato reprovável se, ao final, for comprovado enquadra-se perfeitamente em evidente tráfico ilícito de entorpecentes, o mesmo não se pode dizer quanto à adequação da medida às condições pessoais da acusada (artigo 282 do Código de Processo Penal) e do próprio nascituro, a quem certamente não se pode estender os efeitos de eventual e futura pena, nos termos do que estabelece o artigo 5º, XLV, da Constituição Federal”, ressaltou o presidente da Corte.

O ministro Lewandowski salientou ainda o fato de a Penitenciária Feminina da Capital encontrar-se com o número de presas 13% acima de sua capacidade, fato que comprometeria a segurança e o adequado tratamento médico.

Direitos Humanos

Além da legislação brasileira, o ministro Lewandowski buscou fundamento em normas internacionais de direitos humanos, ao lembrar que, “durante a 65ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, realizada em dezembro de 2010, foram aprovadas as Regras Mínimas para Mulheres Presas”.

Essas regras obrigam os Estados-membros da ONU, inclusive o Brasil, a “desenvolverem opções de medidas e alternativas à prisão preventiva e à pena especificamente voltadas às mulheres infratoras, dentro do sistema jurídico do Estado-membro, considerando o histórico de vitimização de diversas mulheres e suas responsabilidades maternas”.

Destacou ainda que tais regras “são dirigidas às autoridades penitenciárias e agentes de justiça criminal, incluindo os responsáveis por formular políticas públicas, legisladores, o ministério público, o judiciário e os funcionários encarregados de fiscalizar a liberdade condicional envolvidos na administração de penas não privativas de liberdade e de medidas em meio comunitário”.

Desde o seu discurso de posse no cargo de presidente do STF, o ministro Ricardo Lewandowski expressa o desejo de que os membros do Poder Judiciário brasileiro observem e apliquem os entendimentos das Cortes de Direitos Humanos, integrando-os à prática jurídica do País, citando que “é preciso, também, que os nossos magistrados tenham uma interlocução maior com os organismos internacionais, como a ONU e a OEA, por exemplo, especialmente com os tribunais supranacionais quanto à aplicação dos tratados de proteção dos direitos fundamentais, inclusive com a observância da jurisprudência dessas cortes (grifei)”.

É possível, então, defender a tese de que o Brasil reinseriu-se na sistemática da proteção internacional dos direitos humanos. Com isso redimensionou a cidadania, que, além de nacional, expande suas fronteiras para o âmbito internacional.

Nessa ordem de ideias, mesmo na ótica do direito internacional, não se pode mais estabelecer a primazia dos interesses da Administração Pública sobre os direitos legítimos dos seres humanos.

Fala-se, modernamente, no Movimento do “Direito Internacional dos Direitos Humanos”, por meio do qual os direitos humanos não constituem assunto limitado à esfera doméstica dos países, mas um Código comum aos Estados, ao qual todos os Estados devem-se subordinar. A denegação dos direitos humanos enseja a responsabilidade internacional do Estado, independentemente da nacionalidade das vítimas.

Isso quer dizer que o sistema normativo de proteção internacional dos direitos humanos atribui ao indivíduo status de sujeito de direito internacional. Tanto que os tratados internacionais de direitos humanos afirmam a personalidade internacional do indivíduo, endossam a concepção universal dos direitos humanos e

impõem, no plano internacional, obrigações dos Estados que os ratificam. Como se nota, a interpretação aqui desenvolvida ampara-se não somente na principiologia e em regras da Constituição Federal, mas também no desenrolar de normas internacionais de proteção dos direitos humanos, ambas de observância obrigatória pelos Poderes da República.

Nesse sentido, decidiu o egrégio Colégio Recursal de Jales/SP:

Recurso Inominado. Policial Militar. Pleito de remoção. Situação excepcional referente a tratamento de saúde de familiar. Inteligência do regulamento interno para movimentações. Precariedade da situação. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1005227-04.2021.8.26.0297; Relator (a): Paulo Victor Alvares Gonçalves; Órgão Julgador: 4ª Turma Cível e Criminal; Foro de Jales - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 26/11/2021; Data de Registro: 29/11/2021)

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido, de tal sorte que se determina à requerida que remova a parte autora, para residir na sede da 2ª CIA PM – 2ª Companhia da Polícia Militar (Jales-SP) ou em qualquer das unidades policiais ou cidades (GPPMs – Grupo Policial Militar) que fazem parte da 2ª CIA PM.

Defere-se a gratuidade da justiça à parte autora.

Mantém-se, hígida, a tutela antecipada concedida, caso não suspensa pelo egrégio Colégio Recursal de Jales-SP.

Sem condenação em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios – incabíveis nas sentenças proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Em caso de interesse recursal, a(s) parte(s) não isenta(s) deverá(ão) observar também o PROVIMENTO CSM Nº 2.195/2014, que regulamenta, entre outros, o art. 4º, §4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, ao dispor sobre as despesas postais com citação e intimação, bem como o COMUNICADO CG Nº 1817/2016 (Processo CPA Nº 2012/139498 - SPI), da Corregedoria Geral da Justiça, sobre a necessidade do recolhimento da taxa da carta AR Digital, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita” (Lei nº 9.099/95, art. 54, parágrafo único).

P. I.

Jales, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA